

0004372-40.2015.8.26.0010

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: Tatiana Franklin Regueira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/02/2022

... que permita e estimule a prática do tráfico de entorpecentes. A incidência de qualquer benefício não retira do crime de tráfico de drogas o seu caráter hediondo. Pensar desta forma significaria passar por cima da vontade do legislador constituinte que, por meio do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, procurou estabelecer tratamento mais rigoroso ao referido delito. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, 1º andar - Rua 3 - sala 160, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: 2127-9017/ 9018, São Paulo-SP - E-mail: sp9cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:0004372-40.2015.8.26.0010 - 2016/000637Classe - AssuntoProcedimento Especial da Lei AntitóxicosRéu:Johnny Carlos

Aos 8 de fevereiro de 2022, às 15:30 HORAS, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 9ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, Doutora Tatiana Franklin Regueira, comigo Assistente, foi declarada aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento designada nestes autos. Apregoados, compareceram o (a) Digníssimo (a) Promotor (a) de Justiça, Dr. (a) Fabiano Augusto Petean, o réu Johnny Carlos e seu(sua) Defensor(a) Dra. Gisela Camillo Casotti Teixeira, Defensoria Pública do Estado de São Paulo OAB 999999/DP. Declarações e depoimento(s) colhido(s) pelo sistema audiovisual, gravados na plataforma Teams, com a concordância dos presentes. A qualificação dos presentes foi, nesta data, atualizada no sistema eletrônico e se encontra à disposição das partes, com as ressalvas do Provimento CG 32/2000, em se tratando de vítima ou testemunha protegida. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas as testemunhas Manoel e Mario, após o que o réu foi interrogado. AS PARTES NÃO SE OPUSERAM QUE A AUDIÊNCIA OCORRESSE PELO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Pela Defesa foi dito que: : MMª Juíza, nada a requerer na fase do art. 402 do Código de Processo Penal. Em seguida, pela MMª Juíza de Direito foi dito: Não havendo outras diligências a serem empreendidas nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/08, dou por encerrada a instrução criminal, iniciando-se os debates.

Dada a palavra ao (à) Dr. (a) Promotor (a) de Justiça, por ele (ela) foi dito que: MMA. Juíza: O réu JOHNNY CARLOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 18 de novembro de 2015, por volta das 12h10, na Rua Gílias, na altura do n.º 700, Vila Prudente, nesta cidade e comarca da Capital, trazia consigo e transportava para entrega a consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, dentro de uma sacola plástica branca, com peso bruto de 23,7 gramas, contendo substância esverdeada semelhante à maconha, devidamente apreendida (fls. 08). O feito teve seu trâmite regular. A denúncia foi recebida. A defesa foi apresentada. Em instrução foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado. O pedido de condenação é procedente. A materialidade está consubstanciada no auto de termo circunstanciado, no auto de exibição e apreensão, no laudo de constatação e no laudo de exame químico-toxicológico e nos depoimentos colhidos nos autos. A autoria também é certa. Mário Adriano Venturim Gonçalves, policial civil, recordou-se dos fatos. Salientou que tinha muita reclamação de usuários de entorpecentes. Todavia, não se recordou do réu. Salientou que conduziram várias pessoas, sendo que tinha uma pessoa que tinha um violão. Confirmou que trabalhava com o policial Bartolomeu. Manoel Bartolomeu Galvão, policial civil, salientou que foi apreendida uma porção de maconha ao lado do réu, sendo que o réu estava com o violão e com a sacola plástica que tinha a maconha. Afirmou que os vizinhos diziam que tinha tráfico no local e uso, sendo que o réu disse que era para uso próprio. Salientou que o réu estava tocando violão na época. Não se recorda se o réu disse que morava no local. Os vizinhos reclamavam muito do local de uso de entorpecentes. Não há como se pretender reduzir o valor dos depoimentos policiais, questão já superada há muito pela jurisprudência. Confira-se: “O depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional” (TJSP, RT 752/589). “Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (TJSP, RT 616/286/287). “O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF, HC 73518-5, Rel. Celso de Mello – DJU 18.10.96 p. 39.846). Não pode mesmo ser aceita nenhuma crítica infundada contra os relatos das testemunhas. A respeito desse assunto, assim fundamentou o eminente Desembargador José Renato Nalini: “é valioso o depoimento de policiais em hipóteses como a presente. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável. Seria até perigoso envolver cidadãos que não são remunerados para reprimir a criminalidade em diligências potencialmente vulneradoras de irrecuperáveis bens da vida como a narrada nestes autos” (TJSP - Autos de Apelação nº 141.299-3/3 - Segunda Câmara - v.u.). No mesmo sentido, STJ: RT 771/556; TJSP: RT 433/386-7, 715/439, 737/606; TACrimSP: RJTACRIM47/274, 46/282, 46/107, 46/100, 35/218, 35/303, 21/118, 22/326-7, 30/456. O réu JOHNNY CARLOS foi interrogado e afirmou que o violão estava ali e estava com a banda “passando as músicas”. Na época fumava maconha naquele local. Os policiais abordaram à paisana. A droga era sua e não se recorda o quanto tinha. Confirmou que a droga ia ser usada por todos. A defesa ainda tentou transmudar os fatos, para que o réu dissesse que a drogas seria somente sua. Diante dos fatos, restou comprovado que, na data dos fatos, o denunciado estava em uma rua sem saída com corredor lateral, local conhecido como “ponto de tráfico de drogas”, portando algo suspeito, tendo em vista as circunstâncias os policiais civis o abordaram, localizando uma sacola plástica contendo o entorpecente. Em seu depoimento, o denunciado sustentou que a droga era de sua propriedade, haja vista que seria usuário de drogas e estavam ao lado para que pudesse tocar violão. Mencionou que adquiriu. Todavia, a quantidade de drogas

adquirida pelo denunciado é muito elevada para uso próprio, sendo sua versão pouco convincente sobre ter comprado o alucinógeno e o ter esquecido, além de sua detenção ter ocorrido em local conhecido como de intenso tráfico de drogas, não havendo nenhuma testemunha, sequer, da versão de ele adquirira a drogas, sendo plausível que trazia aquela quantidade, para dela fazer pequenas porções que se destinassem ao comércio ilícito que ele exerceria. Quanto à dosimetria de pena, na primeira fase de fixação da pena, constata-se que, na época dos fatos, o réu era primário. Por isso, a pena deve ser fixada no mínimo legal. Nas segunda e terceira fases de fixação da pena, não há considerações a serem efetivadas. É incabível a concessão de benefícios, diante da dedicação do acusado às práticas criminosas do tráfico com os fatos apurados. Em relação ao regime de cumprimento de pena, o único adequado é o fechado. O art. 33, §3.º, do Código Penal, permite, inclusive, a fixação de outro regime, nos casos em que for recomendado, vale dizer, nos casos em que as circunstâncias judiciais do art. 59 forem favoráveis. Não é o caso em questão. O réu praticava o tráfico que, como é de conhecimento notório, tem alta potencialidade lesiva, representando alto grau de periculosidade para a saúde da sociedade. Portanto, caso seja fixado regime mais benéfico ou substituição de pena (o que é inadmissível), não haveria atenção ao proibitivo legal e, realmente, as consequências devastadoras da traficância continuarão a estarem presentes em nossa sociedade. A postulação defensiva é um incentivo ao tráfico, corresponde à descriminalização. Desta forma, observa-se que o regime fechado é o único adequado e suficiente a garantir a devida reprimenda penal, sendo o único a respaldar o combate ao crime pernicioso apresentado. Por isso, tais argumentos já fundamentam o não acolhimento dos argumentos defensivos. Além disso, incabível que a defesa postule, ainda mais, benefício que permita e estimule a prática do tráfico de entorpecentes. A incidência de qualquer benefício não retira do crime de tráfico de drogas o seu caráter hediondo. Pensar desta forma significaria passar por cima da vontade do legislador constituinte que, por meio do art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, procurou estabelecer tratamento mais rigoroso ao referido delito. Ademais, a aplicação de pena restritiva de direitos ao crime de tráfico é absolutamente incompatível com a Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos) que fixa, em seu art. 2.º, §1.º, o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Totalmente incoerente pensar em pena não privativa de liberdade para crime cuja reprimenda deve ser cumprida em regime inicialmente fechado. Por isso, assiste completa razão a este Egrégio Tribunal de Justiça, que já reconheceu, em decisão recente, a impertinência do pedido defensivo. “Ementa: Apelação - Tráfico de entorpecentes - Condenação - Conformismo do condenado, no essencial - Apelo que se limita a pedidos de fixação de regime mais brando e substituição da física por restritiva de direito - Impossibilidade - Regime fechado mantido - Precedentes - Recurso desprovido” (TJSP - Apelação nº 0007553-91.2014.8.26.0072, Comarca de Bebedouro, 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Des. Rel. IVAN SARTORI, 19/04/16). Por isso, qualquer benefício será absolutamente inviável para o acusado no presente feito. Neste sentido, salientamos o precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 195.334/MS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 01/03/2013; HC 240.443/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (Desembargadora Convocada do TJ/SE), QUINTA TURMA, DJe de 22/03/2013). De igual forma, já se decidiu neste Egrégio Tribunal: “Tráfico ilícito de entorpecentes - Imprestabilidade do laudo toxicológico - Preliminar rejeitada - Laudo que dá elementos a identificar o princípio ativo da substância reprimida, ainda que concebida in natura - Prescindibilidade do atestado de grau de pureza - Ausência de argumentos a infirmar a positivação - Materialidade delitiva concebida - Autoria comprovada pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Pena fixada com parcimônia - Regime fechado que melhor se ajusta ao início do cumprimento da aflição - Questão da constitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90 que não se mostra produtora à hipótese - Inviabilidade da substituição da carcerária por restritivas de direitos - Recurso desprovido” (Relator(a): Marcelo Gordo; Comarca: São Pedro; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 05/05/2016; Data de registro: 11/05/2016) (grifo nosso). Ante o exposto, requeiro a condenação do acusado nos

exatos termos da imputação contida na denúncia.

Dada a palavra ao (à) Dra. Defensora, por ele (ela) foi dito: alegações orais.

A seguir, pela MM<sup>a</sup> Juíza de Direito, foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. Johnny Carlos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, supostamente no dia 18 de novembro de 2015, por volta de 12hs10min, na Rua Gílias, altura do número 700, Vila Prudente, nesta Capital, trazia consigo e transportava para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dentro de uma sacola plástica branca, com peso bruto de 23,7 gramas, substância esverdeada semelhante à "maconha". A denúncia foi recebida às fls. 40/41, o acusado foi citado à fl. 48, apresentou defesa à fl. 53 e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, conforme fl. 55, momento em que ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu. Ao final, realizaram-se os debates. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência de fl. 06, auto de exibição e apreensão de fl. 07, laudo de constatação de fls. 72/73 e pelo laudo do exame químico-toxicológico de fls. 74/76. A ação penal, contudo, é parcialmente procedente. Assim porque o conjunto probatório carreado nos autos não deixa patente que a droga apreendida em poder do réu se destinava a posterior entrega a consumo de terceiros, o que obriga a desclassificação delitiva para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.. Coram Iudice o réu negou a prática delitiva. Disse que no dia dos fatos estava tocando violão com pessoas de sua banda no final do beco, da rua onde morava à época, quando foi abordado pelos policiais à paisana. Estava com um quadradinho de "maconha" que se destinava ao próprio consumo. Demais disso, o policial civil Manoel Bartolomeu Galvão narrou que no dia dos fatos havia recebido ligação de vizinhos para averiguação no local dos fatos. O réu foi surpreendido com uma porção do "maconha". Pelo que se recorda o réu estava tocando violão quando chegou no local e disse que a droga se destinava ao próprio consumo. Não foi presenciado ato de mercancia. No mesmo sentido o policial civil Mário A.V. Gonçalves disse que o local é conhecido local de usuário de entorpecentes e costumeiramente recebia ligações de moradores reclamando que tinham pessoas fumando drogas no local. Ante tal conjunto probatório – prova oral e a quantidade de droga apreendida em poder do réu - não é o suficiente para comprovar a intenção do réu de vendê-la para consumo de terceiros. Desta feita, diante da fragilidade do conjunto probatório, incapaz de embasar um decreto condenatório para o delito de tráfico de entorpecentes, desclassifico a infração para o tipo descrito no art. 28 da Lei Antitóxicos. A interpretação há de ser favorável para o acusado, pois não se admite a prolação de uma sentença condenatória, mormente por crime grave como tráfico de entorpecentes, que traz pena severa, se não houver elementos contundentes de prova que conduzam à certeza da prática do delito. Nestes autos, há, sem sombra de dúvidas, prova quanto a propriedade da droga pelo acusado e indícios de que ele é usuário. Por outro lado, não há prova segura quanto ao tráfico de entorpecentes, razão pela qual não é possível imputar ao réu a prática de tal infração penal. Assim, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", merece prosperar a desclassificação para crime de porte de entorpecente para uso próprio. A conduta do réu, portanto, deve ser subsumida no artigo 28, da Lei nº. 11.343/06. Provadas, portanto, a autoria e materialidade, passo a fixar a pena. Provadas, portanto, a autoria e materialidade de uso de entorpecente, passo a fixar a pena. Nos termos do art. 59, do C.P., observada a quantidade de droga apreendida em poder do réu e sua primariedade, aplico tão somente da pena de advertência, nos termos do inciso I, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, pena esta que torno definitiva na ausência de outras circunstâncias modificativas. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para condenar Jhonny Carlos, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência. Em razão da pena aplicada, o réu poderá apelar em liberdade. Isento de custas. Publicada em audiência. Registre-se. Saem os presentes intimados"

Dada a palavra ao (à) Dr. (a). Promotor (a) de Justiça, pelo (a) mesmo (o) foi dito que: MM<sup>a</sup> Juíza, Ciente da sentença, este (esta) Promotor (a) de Justiça não apela.

Dada a palavra ao (à) Dra. Defensora, foi dito: Ciente da sentença. Não desejo apelar da decisão.

O réu tomou ciência da sentença e manifestou o desejo de não recorrer da decisão.

Em seguida, pela MM. Juíza foi dito que: Diante da ausência de recursos pelas partes, certifique-se o trânsito em julgado. Cumpra-se o quanto determinado na sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as comunicações necessárias e a observância das formalidades legais. Saem os presentes intimados.

Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Eu, Luciana Emiko Fukassawa, Assistente Judiciário, digitei e assino digitalmente.